

1501665-40.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501665-40.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501665-40.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE QUEIROZ DA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

FELIPE QUEIROZ DA SILVA, OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS e RAFAEL BATISTA GONÇALVES foram denunciados por incursão, por duas vezes, no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, em concurso formal. OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS também foi denunciado por incursão no caput do art. 180 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 04h48min, na Avenida Barão de Mauá, 3126, RP12 (Regiões de Planejamento), nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos entre si e com uma pessoa não identificada, os acusados subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência contra Carlos Eduardo dos Santos Candido, Jennifer Cristina de Oliveira e Sarah de Matos Pereira, um aparelho celular, pertencente a um cliente do estabelecimento comercial ainda não identificado, um aparelho celular Iphone 11 e uma corrente de prata, pertencentes a

Carlos Eduardo dos Santos Candido.

Consta, ainda, que no dia 29 de agosto de 2022, após o crime acima descrito, entre a Avenida Barão de Mauá, 3126 e a Rua Antônio Negrini, 100, Parque Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado OZIAS recebeu e conduziu o veículo GM/Corsa Milenium, de cor prata, chassi 9BGSC19Z02B178823, placas originais DDH-4D90, mas ostentando placas GSF-2F30, pertencente a Marcos Antônio Xavier Santos, coisa que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 152-4) e apresentaram resposta à acusação.

As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se os réus.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, o reconhecimento de crime único ou do concurso formal próprio em relação ao roubo, a fixação da pena no patamar mínimo, a declaração de inconstitucionalidade material da fração de aumento em razão do emprego de arma de fogo, bem como a fixação de penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 15-21 e 22-3), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 09-11), auto de exibição e apreensão (fls. 27-8), auto de avaliação (fls. 29-30), auto de entrega (fl. 31), laudo pericial da arma apreendida (fls. 168-75), laudo pericial do veículo (fls. 286-90) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogados, em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 12-4).

Sob o contraditório, o réu Felipe negou a acusação e alegou que a policial militar ouvida em Juízo não se conformou pelo fato de ter sido solto após outra abordagem por ela realizada e imputou-lhe a autoria deste delito (mídia digital).

Ozias disse que apenas ficou no interior do carro, mas não planejou nada. Afirmou que não sabia que os demais ocupantes do veículo iriam praticar o roubo em questão. Não quis identificar os passageiros, mas informou que Felipe apareceu depois (mídia digital).

Por sua vez, o réu Rafael também negou a prática delitiva. Relatou que estava saindo de uma festa, embriagado, quando visualizou um veículo prata capotando dentro de um rio. Chegou próximo ao carro para ajudar e viu três pessoas correndo. Na sequência, foi abordado pela polícia e levado como um dos envolvidos no roubo (mídia digital).

A negativa dos réus está totalmente isolada do conjunto probatório.

A vítima Sarah, na fase inquisitiva, declarou que (sic) "é funcionária de uma tabacaria situada na Avenida Barão de Mauá. Estavam próximo do horário de encerramento das atividades, ocasião em que três indivíduos ingressaram no estabelecimento, os quais reconhece como Felipe Queirós da Silva, Ozias Domingos

dos Santos e Rafael Batista Gonçalves. Felipe e Rafael portavam arma de fogo e subiram a escada que dava acesso ao caixa, onde estava juntamente com a vítima Jennifer. Ozias ficou na escada dando guarida à ação dos assecclas, não percebendo se ele estava, de fato, portando arma de fogo. Tentou se esconder num armazém situado no estabelecimento, mas os agentes a perseguiram, tendo Felipe, valendo-se de ameaça com a arma de fogo que portava, exigido o aparelho celular da depoente e de Jennifer que negaram estar em poder dos aparelhos. Os agentes então retornaram ao caixa, onde subtraíram um aparelho que estava no balcão, que pertencia a um cliente que havia deixado o aparelho carregando e acabou por esquecê-lo no local. A vítima Carlos estava no local e avistou a cena, tentando intervir. Entretanto, teve sua corrente e seu aparelho celular subtraídos pelos agentes que deixaram o local. Depois disso nada mais viu ou ouviu sobre a fuga dos roubadores. Soube momentos depois que haviam sido capturados pela polícia tendo então comparecido ao Plantão Policial da cidade de Mauá, onde reconheceu formalmente sem sombra de dúvidas os três indiciados como os autores do roubo" (fl. 06).

No mesmo sentido as declarações da ofendida Jennifer, que apenas acrescentou que (sic) "após a saída dos agentes apenas ouviu populares gritando 'pega ladrão'. Na parte externa do imóvel. Não viu em que veículo eles se evadiram." Na ocasião, ela também reconheceu os três acusados, com certeza (fl. 07).

Durante a instrução, a vítima Sarah reafirmou que estava trabalhando no caixa do estabelecimento, quando dois indivíduos, um deles armado, ingressaram no local e pediram que ficasse quieta. Ato contínuo, gritou e correu, mas eles foram atrás. Pelo que soube, dois roubadores subiram, enquanto o outro ficou na escada. Eles subtraíram bens de dois clientes. Durante a prática delitativa, ficou escondida, pois estava muito assustada, mas conseguiu ouvir gritos de populares acionando a polícia que, logo depois, conseguiu deter os roubadores. Esclareceu que, embora somente dois agentes tenham subido até o estabelecimento, reconheceu os três acusados, pois este terceiro entrou em um carro prata com os demais. Afirmou que após ouvir os gritos na rua, foi até a janela e viu os três suspeitos. Na delegacia, reconheceu os três acusados. Dos indivíduos que ingressaram no local, o primeiro era bem alto e moreno e o outro era mais baixo e branco. O terceiro, que viu pela janela, tinha estatura mediana. Em audiência, reconheceu o réu Ozias e um preso que não tem relação com os fatos em comento (mídia digital).

A vítima Carlos, na fase antejudiciária, narrou que (sic) "estava numa tabacaria situada na Avenida Barão de Mauá. Estava na fila do caixa para pagar a conta e ir embora. Nesse momento, percebeu que o estabelecimento estava sendo assaltado. Visualizou um indivíduo que reconhece como sendo Rafael Batista Gonçalves ameaçando as funcionárias com uma arma de fogo, exigindo aparelhos celulares. Outro agente, que reconhece como sendo Rafael Batista Gonçalves o acertou com a coronha de uma arma de fogo e subtraiu sua corrente e seu aparelho celular. Relata que havia um terceiro agente na escada mas não conseguiu visualizar suas características físicas. Após subtraírem seus bens os agentes evadiram-se do local. Nesse momento, foi até a janela do estabelecimento onde viu os agentes ingressando num veículo marca GM, modelo Corsa de cor prata e evadindo-se do local. Nesse momento, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local sendo advertida por pessoas não identificadas e pelo próprio declarante que tratava-se de um roubo em andamento. Assim, visualizou os policiais saindo no encalço do veículo GM Corsa. Soube momentos depois que os agentes haviam sido detidos. Presente no Plantão Policial de Mauá constatou que seus pertences não foram recuperados. Entretanto, reconheceu formalmente, sem sombra de dúvidas, Felipe Queiroz da Silva e Rafael Batista Gonçalves como autores do roubo. Não tinha condições de proceder o reconhecimento do terceiro agente, uma vez que, conforme já esposado, não viu suas características" (fl. 05).

Durante a instrução, confirmou que foram subtraídos bens pessoais seus e um telefone de outro cliente. No local, visualizou três indivíduos, todos armados.

Dois deles subiram para o andar de cima, enquanto o terceiro permaneceu na escada. Após a captura, reconheceu os três acusados. Descreveu os indivíduos como sendo dois morenos, um alto e outro de estatura mediana, e um branco de estatura baixa. Apesar de estarem usando máscara de proteção, reconheceu-os pelo olhar. Em audiência, reconheceu os réus Ozias, Felipe e Rafael (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que “todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas” (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso, seu valor de “precioso elemento de prova subsidiária” (RT 176/149 –apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine). Não fosse bastante, as pessoas postas para reconhecimento, de acordo com as possibilidades do local de prisão, guardavam relativa semelhança.

Acresce-se que, na fase administrativa, o reconhecimento também observou as formalidades legais, de acordo com o que se depreende da documentação juntada aos autos (fls.09-11).

Os policiais militares, em solo policial, historiaram que (sic) “faziam patrulhamento ostensivo pela comarca de Mauá, ocasião em que ao passarem pela Avenida Barão de Mauá, avistaram um indivíduo, ora identificado como Felipe Queirós da Silva, atravessando a via com uma arma de fogo em punho. Felipe estava acompanhado de mais três indivíduos, dois deles identificados como Ozias Domingos dos Santos e Rafael Batista Gonçalves. Pessoas não identificadas alertaram os policiais que tratavam-se de roubadores que acabaram de praticar um assalto. Os indivíduos ingressaram num veículo marca GM, modelo Corsa Millenium, ostentando as placas GSF2F30, ano/modelo 2002, cor prata e evadiram-se do local com Ozias Domingos dos Santos assumindo a condução do auto. Diante dos fatos, passaram a fazer um breve acompanhamento ao veículo ocupado pelos suspeitos, até que o auto perdeu o controle e caiu num córrego na Rua Antônio Negrini nesta comarca de Mauá. Felipe Queirós da Silva, Ozias Domingos dos Santos e Rafael Batista Gonçalves foram contidos no local, onde também foi apreendida a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, um revólver, calibre .38, marca Taurus de numeração 21228662 encontrada em poder de Felipe Queiroz da Silva. O quarto componente do grupo de roubadores conseguiu se evadir do local a pé, tomando rumo ignorado. Assim, foram os roubadores encaminhados para a Delegacia de Polícia. O veículo, que constatarem ser produto de furto, praticado em julho deste ano conforme B0 DB8392/2022 e a arma de fogo arrecadados foram apresentadas no Plantão Policial” (fls. 03-4).

Em juízo, a policial militar Letícia reiterou integralmente a dinâmica da prisão dos suspeitos, confirmando que, logo após a prática do roubo, visualizaram um indivíduo moreno e alto embarcando em um veículo com uma arma de fogo na mão. Em seguida, iniciou-se o acompanhamento, ocasião em que o condutor perdeu o controle do automóvel e caiu em um córrego. Em razão do acidente, os ocupantes do carro foram detidos. No veículo, localizaram dois celulares. A arma de fogo foi encontrada nas proximidades do carro. Informalmente, o moreno admitiu a prática do roubo, enquanto os demais disseram que ficaram no veículo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de

menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelas vítimas e pela policial militar está em perfeita harmonia àquele por elas prestado perante a Autoridade Policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que elas tivessem motivo particular, injusto, para falsamente incriminar os réus.

Descabida a alegação da Defesa de que a vítima Sarah mentiu porque teria omitido que os réus usavam máscaras, uma vez que a máscara de proteção não impede o reconhecimento, a vítima Carlos esclareceu que apesar de estarem usando máscara de proteção, reconheceu os acusados pelo olhar, inclusive. No mais, em que pese a policial militar, em solo policial, ter dito que viu quatro pessoas, em juízo afirmou que viu três pessoas saindo do veículo, o que condiz com os depoimentos das vítimas.

Além disso, a vítima Carlos reconheceu, em juízo, os réus, enquanto que a vítima Sarah -que tinha reconhecido os três acusados na fase administrativa, logo após os fatos-, em juízo, reconheceu apenas o réu Ozias.

Assim, diante da prisão dos réus, logo após a prática do roubo, na posse da arma de fogo e do veículo utilizados no roubo, do depoimento da policial militar confirmando que viu um dos acusados embarcando no veículo com uma arma de fogo na mão, das declarações seguras das vítimas sobre a participação dos réus no delito, além dos reconhecimentos na fase antejudiciária e em juízo, a responsabilidade penal dos denunciados é incontroversa.

No mais, as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra das vítimas e da policial militar, e pelo laudo pericial de fls. 168-75.

Registre-se que o recrudesimento do roubo praticado com arma de fogo, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não é inconstitucional por afronta ao princípio da proporcionalidade. É evidente a maior periculosidade dos indivíduos que praticam roubos com a utilização de arma de fogo, razão pela qual é necessária sanção mais rigorosa. Sobre o tema:

"Em que pese a alongada manifestação lançada pela Defensoria Pública, não se constata "vício" com relação à hipótese prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, fruto da alteração legislativa promovida pela Lei nº. 13.654/2.018, que estipulou aumento de dois terços (2/3) de pena diante do roubo praticado com emprego de arma de fogo. Nesse tom, a forma "majorada" estampada no verbete em destaque traduz a preocupação do legislador em punir de forma mais severa aqueles que se utilizam do artefato para vencer por completo a capacidade de resistência das vítimas, não se ignorando, ademais, que a prévia aquisição do instrumento demanda maior grau de planejamento e preparação por parte dos criminosos, além de o objeto expor a perigo concreto a integridade física das vítimas e de terceiros, tudo justificando o maior rigor conferido pelo legislador, atento ao princípio

constitucional da proporcionalidade. No caso, impossível se ignorar o acentuado potencial vulnerante da arma de fogo frente aos demais artefatos que também delineavam a majorante prevista no revogado artigo 157, § 2º, I, daquele Estatuto Repressor, os quais voltaram a ser contemplados no inciso VII do verbete em destaque com o advento do "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2019) que, inclusive, referendou a distinção de tratamento diante do roubo cometido mediante emprego de armas brancas e daquele perpetrado com artefatos explosivos ou armas de fogo. Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara sobre o tema ao lembrar o óbvio: "... o intuito do legislador, com a promulgação da Lei nº 13.654/18, foi punir mais gravemente o roubo praticado com o emprego de arma de fogo (e com razão, diante da violência urbana incontrolável que assola e macula a sociedade ordeira, situação para a qual o Estado não pode fechar os olhos), sendo estrábica para não dizer de má-fé qualquer alegação tendente a sugerir sua ineficácia" (TJESP, Apelação Criminal nº. 1501374-45.2018.8.26.0228, Relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado 10-10-2019). Ainda a respeito, "a diferença de tratamento trazida pela Lei n. 13.654/2018 se amolda ao princípio da proporcionalidade, eis que pune, de forma mais rigorosa, o delito cometido com emprego de arma de fogo, diferentemente do praticado com outras armas. Ora, o emprego de arma de fogo, para ameaçar a vítima, aumenta a probabilidade de dano à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas, bem como facilita a execução do crime. Desta forma, a conduta deve ser punida de forma proporcional à sua gravidade" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0036696-55.2018.8.26.0050, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 21-03-2019). No mais, convém notar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte se manifestou sobre a higidez do processo legislativo e constitucionalidade formal do diploma alterador (Incidente de Inconstitucionalidade sob o nº. 0017563-80.2018.8.26.0000, Relator Desembargador ALEX ZILENOVSKI, julgado 05-09-2018), sem em nenhum momento sinalizar eventual vício capaz de obstaculizar a aplicação da norma por este Egrégio Tribunal. E as "comparações" entre tipos/conduas feitas pela Defesa, de tão absurdas, servem até mesmo para reforçar o tratamento distinto dado pelo legislador, dada a óbvia diversidade de delitos, abarcando objetos jurídicos bem diferentes" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0002790-48.2021.8.26.0348, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, julgado em 17 de março de 2022).

"Apelação da Defesa. Tentativa de roubo com o emprego de arma de fogo. Provas suficientes à condenação. Réu detido em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima. Negativa do acusado isolada do contexto probatório. Causa de aumento bem demonstrada. Laudo pericial suficiente a demonstrar a eficácia da arma de fogo apreendida. Inconstitucionalidade material da causa de aumento. Inocorrência. Patamar de exasperação adequado à maior gravidade da conduta, que expos a risco a integridade física da vítima. Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do réu. O período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não afasta os maus antecedentes. Precedente do STF - Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida. Pena elevada em 2/3 na terceira fase da dosimetria. Redução da pena em 1/2 pela tentativa. Patamar adequado ao "iter criminis" percorrido. Regime inicial fechado mantido. Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa. Recurso de apelação desprovido." (AP nº 1502466-58.2019.8.26.0540, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 18.12.20).

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 13.654/2018. AFASTAMENTO. Proporcionalidade justificada pelo legislador, que procurou mesmo enrijecer o tratamento dado a crimes cometidos com o emprego de arma de fogo e explosivos. Exposição de motivos e precedente. Inconstitucionalidade afastada. Exposição de motivos e precedente. Inconstitucionalidade afastada. (...)" (AP nº 1502044-32.2018.8.26.0536, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 06.06.19) g.n.

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. (...) EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E

PERÍCIA. (...) 6. Quanto à etapa derradeira da dosagem da pena, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019). (...) (HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

Por fim, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, não se trata de crime único ou concurso formal próprio. Nota-se que o crime de roubo foi praticado em concurso formal, tendo em vista que, num mesmo contexto fático, atingiu-se patrimônio de duas pessoas (STF, HC nº 73.514, rel. Min. Marco Aurélio; HC nº 70.550, rel. Min. Paulo Brossard, HC nº 70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp nº 662.999, rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp nº 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp nº 152.690, rel. Min. Jorge Scartezzini, HC nº 43.704, rel. Min. Félix Fischer).

Em relação ao crime de receptação do veículo GM/Corsa, praticado pelo réu Ozias, posiciona-se a jurisprudência no sentido de que "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade" (JUTACrim 66/410; RJDTACrim 10/125-127; ver ainda, RJDTACrim 6/132 e 8/96).

Esse entendimento, é verdade, mais parece amoldar-se aos casos de crimes subtrativos do que ao de receptação, e está a tratar-se, por certo, de presunção relativa de responsabilidade, que, como tal, é infirmável; para invalidá-la, tem-se decidido ser ônus da defesa a demonstração de fato justificador da posse, nos termos do que dispõe o art. 156, CPP, com que explicar o empossamento do réu sobre a coisa objeto do crime, maxime quando as circunstâncias apuradas conflitem com uma explicação menos verossímil ou nada fornecida pelo réu, exatamente como no caso dos autos.

Registra-se que o crime de receptação, na grande maioria das vezes, é praticado na clandestinidade e, por isso, o dolo do agente e a prova do conhecimento da origem espúria do bem podem ser extraídos das próprias condutas do acusado, sendo demonstrados por meio de prova indiciária e circunstancial que sendo coesa, firme e concludente, pode autorizar o decreto condenatório. É o caso dos autos. Nesse sentido, vem, reiteradamente, decidindo a jurisprudência:

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (Rel. Renato Mascarenhas - JUTACRIM 83/242).

"Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação" (RJDTACRIM 12/118).

Nesta linha, ainda, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC nº 388.640-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. em 13.06.2017).

Diante desses elementos, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, patente o dolo de dirigia um veículo furtado para praticar roubo, sem nenhuma documentação que legitimasse a posse.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e receptação, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

1-Em relação ao roubo:

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu Rafael no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Em relação aos réus Felipe e Ozias, fixo as penas-base em 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (Felipe - certidão de fls. 68-9 - proc. 8151-32.2010 e Ozias - certidão de fls. 86-7 - proc. 22241-16.2008), atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, aumento a pena do réu Rafael em 1/6, diante da reincidência (cert. fl. 101 -proc 1209-43.2017), perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Considerando que o réu Ozias é reincidente específico (FA fl.97 -Ex. 2 e cert fl.291 -proc 0000022-24.2015) e o réu Felipe é bi-reincidente, sendo uma das reincidências específica, inclusive (FA fl. 83 -Ex.2 -proc 7000439-61.2013 e Ex. 3 -proc 7000989-58.2018), aumento suas penas em mais 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa para o réu Ozias e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa para o réu Felipe.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

"Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016). g.n.

"Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica" (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015). g.n.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014). g.n.

Ainda, o e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) g.n.

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinhoo-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 – grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo

parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 – grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminosa, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o crime foi praticado por três agentes, com emprego de arma de fogo e em estabelecimento comercial, ou seja, com maior risco de exposição da população. Além disso, os agentes utilizaram um veículo receptado para a consecução do roubo e para auxiliar na fuga. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena dos réus em 1/3, pelo concurso de agentes, totalizando 08

anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa para o réu Ozias, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para o réu Rafael e 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa para o réu Felipe.

Na sequência, tendo em vista o depoimento das vítimas, no sentido de que os agentes portavam arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e 30 dias-multa para o réu Ozias, 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias multa para o réu Rafael e 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e 30 dias-multa para o réu Felipe.

Por fim, tendo em vista o concurso formal entre os delitos, foram subtraídos bens de duas vítimas (Carlos e outro cliente), soma-se mais 1/6 às penas, definindo-se as condenações em 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa para o réu Ozias, 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26 dias multa para o réu Rafael e 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa para o réu Felipe.

2-Em relação ao crime de receptação:

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu Ozias em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (cert fls. 86-7 -proc. 22241-16.2008), perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, aumento sua reprimenda em mais 1/6, diante da reincidência (FA fl.97 -Ex. 2 e cert fl.291 -proc 0000022-24.2015), perfazendo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material entre os crimes de roubo e receptação, somam-se as penas, resultando em 17 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão e 47 dias-multa para o réu Ozias.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Além disso, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119). Não bastasse, os réus ostentam péssimos antecedentes.

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu OZIAS DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas 17 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, sob regime inicial fechado, e 47 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão, por duas vezes, no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, em concurso formal, e no caput do art. 180 do Código Penal, em concurso material, o réu RAFAEL BATISTA GONÇALVES, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, sob regime inicial fechado, e 26 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu FELIPE QUEIROZ DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, sob regime inicial fechado, e 35 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão, por duas vezes, no inciso II do parágrafo 2.º e no inciso I do parágrafo 2.º-A, ambos do art. 157 do Código Penal, em concurso formal.

Denego aos condenados o direito de recorrerem em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Transitada em julgado, encaminhe-se a arma de fogo e munições apreendidas (fl. 27) ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03 e art. 1º da Resolução nº 134 do CNJ.

Em relação aos demais bens apreendidos, nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado, desde que comprovada a propriedade. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento do bem, para posterior realização de leilão ou destruição, se o caso.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA